

1501963-15.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUSTAVO HENRICHS FAVERO

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... elemento subjetivo do tipo penal referente ao narcotráfico.

Não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

4ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-001

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501963-15.2020.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501963-15.2020.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2149971/2020 - DEL.POL.CUBATÃO, 11996675 - DEL.POL.CUBATÃO, 593/20/202 - DEL.POL.CUBATÃO, 2149971 - DEL.POL.CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

SAMUEL DOS SANTOS PEREIRA GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO HENRICHS FAVERO

Vistos.

I - RELATÓRIO

SAMUEL DOS SANTOS PEREIRA GOMES foi denunciado e está sendo processado por infração ao artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Isto porque, segundo a denúncia, no dia 21 de junho de 2020, por volta das 17h50, no Caminho Santa Catarina, próximo ao nº10, Cubatão, SAMUEL DOS SANTOS PEREIRA GOMES, qualificado a fls. 19, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, substância entorpecente, cocaína, causadora de dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e de apreensão de fls. 09/10 e auto de constatação provisória de fls. 12. Segundo o apurado, policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina,

pelo local dos fatos, momento em que visualizaram um indivíduo, ora denunciado, em uma motocicleta, sem capacete. Ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu em fuga, porém, foi perseguido e abordado. Ao ser revistado, foi localizado, em sua cintura, 100 "ependorfs" contendo, em seu interior, cocaína (175g - peso bruto). A razoável quantidade de entorpecentes encontrados, o modo de acondicionamento, as circunstâncias da apreensão e os testemunhos dos policiais demonstraram que o denunciado praticava o tráfico ilícito de entorpecentes.

A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2022 (fls. 261/265).

O acusado foi citado e apresentou defesa prévia (fls. 277/278).

Em audiência de instrução realizada, foram inquiridas as testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, a aplicação de regime inicial diverso do fechado e a suspensão condicional da pena.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

II - PRELIMINARES

O processo instaurou-se e desenvolveu-se regularmente, não havendo nulidades a serem declaradas. Com efeito, o Juízo é competente, respeitou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório do acusado.

Ainda, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo alegações das partes de outros vícios processuais.

Inicialmente, gizo que incabível a alegação de que o flagrante foi preparado.

O flagrante provocado ou preparado é aquele em que ocorre a indução ou instigação para que agente cometa o crime, com o fito de se efetuar a prisão. Como ensina RENATO BRASILEIRO DE LIMA, o flagrante preparado, também chamado de provocado, crime de ensaio, delito de experiência ou delito putativo por obra do agente provocador, "ocorre quando alguém (particular ou autoridade policial), de forma insidiosa, instiga o agente à prática do delito com o objetivo de prendê-lo em flagrante, ao mesmo tempo em que adota todas as providências para que o delito não se consuma". (Manual de Processo Penal. 8ª ed. Salvador:JusPodivm, 2020, p. 1.035.) A atuação dos policiais, como se vê, não se amolda à figura do flagrante preparado, mas sim ao que na doutrina convencionou-se chamar de flagrante esperado, em que, "valendo-se de investigação anterior, sem a utilização de um agente provocador, a autoridade policial ou terceiro limita-se a aguardar o momento do cometimento do delito para efetuar a prisão em flagrante" (Manual de Processo Penal. 8ª ed. Salvador:JusPodivm, 2020, p. 1.036).

Assim, dos fatos narrados restou evidente que não houve qualquer tipo de preparação dos agentes policiais para que o Réu cometesse o crime. Não houve qualquer provocação escrupulosamente engengrada, a ensejar o nascedouro ou a gênese da intenção ou volição do Réu para a prática ou consecução da conduta. Ao contrário, os agentes policiais estavam em patrulhamento e perceberam a ocorrência.

Em verdade, o que poderia ter no caso em tela, é um verdadeiro flagrante diferido (ação controlada), conforme previsão contida no art. 53, inc. II da Lei 11.343/06 e no art. 3º, inc. III da Lei nº 12.850/2013. Afinal, esta modalidade de obtenção probatória consiste "em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações" (art. 8º da Lei 12.850/2013).

Logo, o crime - que é permanente - já estava sendo praticado antes mesmo da chegada dos policiais. Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça que se aplica perfeitamente à espécie:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. NÃO HÁ QUE SE CONFUNDIR FLAGRANTE PREPARADO COM FLAGRANTE

ESPERADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. 1. Não se deve confundir flagrante preparado com esperado - em que a atividade policial é apenas de alerta, sem instigar qualquer mecanismo causal da infração. 2. A 'campana' realizada pelos policiais a espera dos fatos não se amolda à figura do flagrante preparado, porquanto não houve a instigação e tampouco a preparação do ato, mas apenas o exercício pelos milicianos de vigilância na conduta do agente criminoso tão-somente a espera da prática da infração penal. (...) 6. Writ denegado (HC 40.436/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 02/05/2006, p. 343).

Ademais, não há quaisquer nulidades quanto a prisão em flagrante, posto que a mesma já fora analisada na audiência de custódia, sendo inclusive homologada. Ultrapassada essa questão prévia, verificada a regularidade do processo, passa-se à análise de mérito.

III - MÉRITO

No mérito, em observância ao princípio constitucional da motivação das decisões (art. 93, inc. IX da CRFB), densificado infraconstitucionalmente pelos arts. 11 e 489, § 1º, inc. IV do CPC - e aplicados ao processo penal na forma do art. 3º do CPP - passo a analisar todas as causas de pedir da acusação e teses defensivas. Destarte, passo ao exame da questão de fundo, aditando que a pretensão punitiva é procedente.

Consente-se que simbolicamente a Lei 11.343, que revogou a Lei 6.368/76 "representa uma nova política na seara das drogas" (HASSON, Felipe. Drogas: Constituição, Democracia e Liberdade. Curitiba: Instituto Memória. Centro de Estudos da Contemporaneidade, 2015.p. 156).

Na seara do Direito Penal, afirmam Zaffaroni e Pierangelli: "todo direito quer regular a conduta humana em sociedade e comina para que os homens se adaptem a suas regulações. Portanto, também, o direito penal tem uma aspiração ética: aspira evitar o cometimento e repetição de ações que afetam de forma intolerável os bens jurídicos penalmente tutelados" (Manual de Direito Penal Brasileiro - Parte Geral. 10ª ed. São Paulo: Editora Revistados Tribunais, 2013. p. 95).

A definição de quais substâncias são consideradas ilícitas se encontra na Portaria SVS/MS n.º 344, de 12 de maio de 1998 (ver artigo 66 da Lei 11.343/06) e nesta definição se incluem todas as previstas no Anexo I (ver, p. ex., REsp. 1.444.537/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016).

A materialidade da infração restou comprovada através dos seguintes elementos de prova colhidos no Inquérito Policial: termo de depoimento (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição/apreensão (fls. 09/10), relatório final (fls. 85/88), além da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que tange à autoria, indubitosa sua atribuição ao réu, uma vez que o material probatório colhido foi suficiente para a formação de seguro convencimento nesse sentido.

É certo que de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação foram corroborados pela prova produzida em contraditório.

Demais, adotando-se o conceito complexo do tipo de Hans Welzel, tem-se que ele apresenta um aspecto objetivo e outro subjetivo. Na ação penal típica, está implícito um juízo de valor. O tipo penal, deste modo, não é composto apenas por elementos objetivos, mas é também integrado por elementos normativos e subjetivos, que vão contornando o conteúdo material do injusto e identificando o bem jurídico tutelado. Em síntese, é a efetiva lesão ao bem jurídico que conduz o intérprete nos caminhos na tipicidade, como se minudenciaria.

Vejamos:

Em solo policial, o condutor e testemunha MACIEL DE MELO SANTOS disse que

"juntamente com seu colega CBPM Dechen RE 136133-3, componentes do 2º Batalhão do Choque informando que estavam em patrulhamento pela Rodovia Padre Manoel da Nobrega, quando acessaram a Marginal que dá acesso ao bairro Vila Esperança e de pronto visualizaram um indivíduo em uma motocicleta sem o uso de capacete, razão pela qual resolveram abordá-lo e assim que tal indivíduo percebeu a aproximação dos policiais empreendeu fuga, ocasionando um breve acompanhamento, até o momento em que na altura do numeral 3270 da avenida principal do bairro Vila Esperança, o indivíduo acabou atropelando um pedestre, e mesmo após a queda, acabou por abandonar a motocicleta no local e se evadiu a pé, seguindo pela Via Caminho Santa Catarina, onde então foi abordado pelos policiais e identificado como SAMUEL DOS SANTOS PEREIRA GOMES. Em revista pessoal, foi encontrado em sua cintura uma sacola plástica com 100 eppendorfs de pó branco aparentando ser cocaína. Inquirido sobre a propriedade da motocicleta, falou que era de um amigo sem recisar detalhes e quanto a droga, nada declarou. O indiciado, então foi conduzido até o pronto socorro central de Cubatão, por apresentar lesões causadas pela queda da motocicleta e posteriormente apresentado nesta Distrital. Já a vítima do acidente foi resgatada pela ambulância do SAMU prefixo 63 e permaneceu internado devido a gravidade das lesões" (fls. 02).

Em Juízo, disse que se recorda da ocorrência. No dia estava em patrulhamento na Avenida Padre Manoel de Nobrega, quando acessaram a marginal para a comunidade "Vila Esperança". Presenciaram o Réu de moto, sem capacete. Quando o Réu presenciou a viatura empreendeu fuga, atropelando um pedestre. Um policial permaneceu com o edrete e o Réu abandonou a moto, correndo para uma via. Com o auxílio de outro policial, o Cabo Dechen, abordaram o Réu e, com o mesmo, havia uma sacola plástica com 100 recipientes de cocaína em sua cintura. Em relação à droga o Réu permaneceu em silêncio. Não conhecia o Réu de outras abordagens. As drogas estavam embaladas para mercancia. Populares falaram que o dono da motocicleta seria o indivíduo que foi atropelado pelo Réu. Pela experiência de 22 anos de polícia entende que a quantidade de droga era para comércio, pois eram 100 eppendorfs. O réu também foi socorrido, medicado e liberado com o acidente de moto. Não se recorda das lesões apresentadas pelo Réu.

Em solo policial, a testemunha DOUGLAS DECHEN disse que "juntamente com seu colega 1º Sgto Maciel RE 136133-3, componentes do 2º Batalhão do Choque informando que estavam em patrulhamento pela Rodovia Padre Manoel da Nobrega, quando acessaram a Marginal que dá acesso ao bairro Vila Esperança e de pronto visualizaram um indivíduo em uma motocicleta sem o uso de capacete, razão pela qual resolveram abordá-lo e assim que tal indivíduo percebeu a aproximação dos policiais empreendeu fuga, ocasionando um breve acompanhamento, até o momento em que na altura do numeral 3270 da avenida principal do bairro Vila Esperança, o indivíduo acabou atropelando um pedestre, e mesmo após a queda, acabou por abandonar a motocicleta no local e se evadiu a pé, seguindo pela Via Caminho Santa Catarina, onde então foi abordado pelos policiais e identificado como SAMUEL DOS SANTOS PEREIRA GOMES. Em revista pessoal, foi encontrado em sua cintura uma sacola plástica com 100 eppendorfs de pó branco aparentando ser cocaína. Inquirido sobre a propriedade da motocicleta, falou que era de um amigo sem recisar detalhes e quanto a droga, nada declarou. O indiciado, então foi conduzido até o pronto socorro central de Cubatão, por apresentar lesões causadas pela queda da motocicleta e posteriormente apresentado nesta Distrital. Já a vítima do acidente foi resgatada pela ambulância do SAMU prefixo 63 e permaneceu internado devido a gravidade das lesões" (fls. 03). Em Juízo, corroborou a narrativa de seu colega de farda.

Em solo policial, o acusado SAMUEL DOS SANTOS PEREIRA GOMES disse que "Na presença de seu advogado Nelson Machado Reis OAB/SP 267007, informa que já foi comunicada sua prisão à sua irmã Maria Aparecida Tel 13-996156246. Cientificado dos motivos de sua prisão e cientificado de seu direito constitucional de permanecer calado, manifestou o desejo de se manifestar nesta ocasião. Com relação aos fatos alegou que estava em um churrasco, quando acabou a carne e pegou a motocicleta de seu colega Richard, mediante sua autorização. Após ir até um açougue que estava fechado, resolveu "dar umas voltas" com a motocicleta, quando estava transitando pela avenida principal, se assustou com a chegada das motocicletas dos policiais

militares, e pelo fato de não estar usando capacete, ter ingerido bebida alcoólica e de não ter habilitação, acabou agindo pela emoção e acelerou a motocicleta. Alguns metros depois, próximo de onde estava tendo o churrasco, o indiciado tentou parar a motocicleta ao visualizar seu amigo Richard, porém ela acabou derrapando. Do acidente, Richard e o interrogado acabaram se lesionando. Alega que não fugiu do local, pois foi jogado metros à frente, quando do acidente e lá foi abordado pelos policiais. Afirma que não possuía nenhuma droga e sua abordagem foi testemunhada por conhecidos que estavam defronte ao local, se recordando neste momento de Gustavo, Pâmela, Flavia, além de seu genitor e sua irmã Mayara que chegaram rapidamente no local. Não sabe explicar o motivo pelo que os policiais alegaram que o interrogado estava com drogas" (fls. 04/05).

Interrogado em Juízo, rememorou a versão apresentada em solo policial, isto é, que pegou uma motocicleta emprestada de seu amigo Richard para comprar carne. Entretanto, ficou assustado com a blitz policial e descontrolou a motocicleta, atropelando Richard. Os policiais o abordaram e falaram que seria levado para averiguação por ter abordado um pedestre. Após os exames médicos foi levado para a delegacia e desconhece qualquer droga. Nunca se envolveu com drogas. Não conhecia os policiais e não possui problema com eles.

Pois bem.

Finalizada a instrução processual, ficou suficientemente comprovado que o réu praticou o crime descrito na denúncia, pois a versão apresentada pelo Réu não encontra eco no manancial probatório, quedando-se isolada.

Ademais, a comprovação da natureza entorpecente da substância, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada por perito criminal, o que ocorreu no caso em tela (art. 158 do CPP).

Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o tipo do tráfico de drogas é tipo congruente simétrico, em que o tipo objetivo coincide com o tipo subjetivo, o que significa dizer que não se exige elemento subjetivo específico da mercancia. O tipo do art. 28 da Lei n. 11343/06, este sim, é tipo incongruente, em que o tipo subjetivo está além do tipo objetivo, o que equivale a dizer que se exige a comprovação do elemento subjetivo específico de consumir a droga que porta. Em outros termos, para a condenação no delito do art. 33 da Lei n. 11343/06, e não no art. 28, exige-se tão somente que se afaste, com segurança, a finalidade do consumo próprio, sendo desnecessária a prova da efetiva mercancia (STJ, REsp n. 1134610/MG, rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. 19.08.2010).

E, a despeito de entendimento pessoal em sentido contrário quanto à suficiência dos depoimentos policiais para sustentar a condenação, curvo-me ao entendimento dominante em respeito à isonomia, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC, aplicado na forma do art. 3º do CPP).

O depoimento dos policiais civis deve ser bem avaliado. É verdade que, sem pretender qualquer crítica, sabe-se que a atuação policial é uma atividade administrativa que se situa em um contexto de tensão de direitos fundamentais, de modo que seria ingenuidade recorrer acriticamente ao dogma da presunção de regularidade dos atos dos agentes dos poderes públicos, confundindo vigência (existência do ato e regularidade formal) com validade (conteúdo material constitucionalmente conformado).

Neste sentido, LUIGI FERRAJOLI destaca que "diversamente dos outros ramos da administração pública, é uma atividade em contato direto com as liberdades fundamentais" (Diritto e Ragione. 1998, p. 798, em tradução livre).

Dogmaticamente, o art. 202 do CPP perlustra que "toda pessoa poderá ser testemunha". Ademais, demais, quanto à questão da suspeição de uma testemunha policial, temos que, dada a aplicação do princípio da igualdade (art. 5º, caput e inc. I da CRFB), a mesma estará sujeita tal qual como qualquer outra testemunha ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP). Ora, "a qualidade da testemunha, seu meio de vida, sua profissão, sua reputação ou qualquer outro atributo pessoal não deve produzir efeito algum para impedir a sua atuação" (NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 98). A partir daí, parece evidente que o depoimento de policial somente poderia ser excluído da apreciação judicial se, desde logo, houvesse prova no sentido de que

ele tivesse sido colhido em desrespeito às normas materiais – caso em que a prova deveria ser desentranhada dos autos (art. 157, CPP) –, ou às normas processuais, caso em que o ato seria nulo (art. 563 do CPP). Entretanto, no caso em apreço, a palavra dos policiais merece a credibilidade dos testemunhos em geral, sendo que não há elementos seguros e convincentes que afastam a confiabilidade de tais depoimentos, sobretudo porque o amplo acervo probatório arrolados nos autos encontra-se em consonância com os relatos dos agentes. Com efeito, observa-se que os testemunhos dos funcionários da polícia são harmônicos e descrevem os fatos com clareza, sendo que não há nenhum elemento capaz de colocar tais declarações em dúvida. Essas palavras, produzidas por pessoas isentas, que não tinham razões para prejudicar o acusado – sobretudo porque nada foi levantado neste sentido –, soa mais que suficiente para embasar a condenação, pois, consoante iterativa jurisprudência, nada impede que a condenação se dê com base nas palavras dos policiais. Sobre o tema, já decidiu Col. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017); “...Conforme o entendimento pacífico desta Corte, “o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).” (HC 373.394/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)

Não há nos autos nenhuma informação de que os policiais pretendessem imputar falsamente ao acusado a prática do crime descrito na denúncia, não havendo, portanto, provas que retirem a credibilidade de seus depoimentos. Dúvida não há acerca da prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado. Os relatos comprovam a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, sobretudo porque se trata de delito de tipo misto alternativo, em que a prática de apenas um dos verbos constantes no preceito primário é bastante para a sua caracterização.

Nos termos do art. 28, § 2º da Lei de Regência, notadamente as condições em que se desenvolveram as ações criminosas, denota-se que o acusado, de forma deliberada, guardava e tinha em depósito drogas – verbos nucleares do preceito primário contido no art. 33 –, em elevadíssima quantidade, que seriam distribuídas pelo estado, pelo que é nítida a existência do elemento subjetivo do tipo penal referente ao narcotráfico.

Não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (STF, 1ª T. – HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Cumprе ressaltar que o crime em comento é do tipo misto alternativo, ou seja, o

tipo penal é composto por inúmeros verbos - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, vender, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar - que praticados isolada ou conjuntamente, implicam o cometimento de um crime único, ou seja, basta a prática de apenas uma dessas condutas para que o delito em tela consumar-se. Assim, o ato de "guardar" é apenas uma das condutas que se subsumam ao tipo penal. Sendo desnecessário que o réu seja encontrado no momento que realiza a comercialização do entorpecente, mesmo porque, esse ato, via de regra, se desenvolve na clandestinidade e, no caso em tela, o acusado foi abordado em razão de uma investigação policial já instaurada há meses.

Logo, é inviável se cogitar a absolvição por falta de provas ou negativa de autora do acusado em relação à imputação da prática do delito em comento. Igualmente não há que se falar em atipicidade da conduta.

Assim, considerando tudo que foi exposto, isto é, as circunstâncias que se desenvolveram os fatos, aliados com as informações prestadas em Juízo pelas testemunhas, não restam dúvidas da materialidade do delito praticado pelo Réu. De mais a mais, inexistem causas de excludentes de antijuricidade (art. 23 do CP) ou culpabilidade (arts. 26 a 28 do CP).

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do Réu, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Impõe-se, portanto, a condenação do acusado por infração ao artigo 33, "caput", da lei nº 11.343/06.

IV - DOSIMETRIA DA PENA

Bem delineadas tais premissas, em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI da CRFB) e ao sistema trifásico de Nelson Hungria (arts. 59 e 58 do CP), passo a dosar a reprimenda a ser imposta.

Na primeira fase da dosimetria penal, analisadas as diretrizes dos artigos 42 da Lei n. 11.343/06 e 59 do Código Penal, anoto que, na lição de Guilherme de Souza Nucci, "não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade de substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias do crime, elementos também constantes do art. 59, do Código Penal" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. I, 6.ª ed., RT, São Paulo: 2012, p. 286). Significa dizer que o legislador explicitou no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, algumas circunstâncias que deverão ser levadas em conta pelo julgador, nos termos do art. 59 do Código Penal, transformando-as em preponderantes. Destarte, em observância às circunstâncias judiciais previstas no art. 42 c/c art. 59, do Código Penal, verifico que: a) Culpabilidade: foi normal, não necessitando o réu de punição acima do mínimo para sentir os efeitos da reprovação de sua conduta, e também para a prevenção especial e geral do crime ora analisado. b) Antecedentes: o réu não ostenta maus antecedentes. c) Conduta social: não foram colhidos elementos suficientes para sua aferição. d) Personalidade do agente: nada há nos autos a possibilitar sua aferição. e) Motivos do crime: entendidos como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, foram próprios do tipo penal, não havendo nada a se valorar. f) Circunstâncias do crime: entendidas como o modus operandi (as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do tipo) são neutras, na medida em que inerente ao tipo penal. g) Consequências do crime: entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado não transcendem à espécie, embora reprováveis. h) Comportamento da vítima: não influenciou a prática das infrações.

Assim, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria penal, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria penal, de acordo com o constante dos autos, o réu possui 21 anos, é primário e não detém antecedentes. Embora não tenha comprovado ocupação lícita, não foi demonstrado durante a instrução criminal que estava se dedicando a atividades criminosas ou pertencia a organização criminosa - ônus que competia à acusação (art. 156 do CPP) -. Portanto, possível a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11343/06, sob pena de se esvaziar por completo a aplicação da causa redutora e de violação dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

Assim a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11343/06 exige fundamentação idônea. A ausência de provas do envolvimento em atividades criminosas ou a participação em organização criminosa deve ser interpretada em benefício do acusado e, por conseguinte, não é suficiente para afastar a aplicação da causa de redução de pena. Incidência do princípio da presunção de inocência e da regra in dubio pro reo" (STF, HC 103225-RN, 2ª T. rel. Min. Joaquim Barbosa, 11.10.2011, v.u). No mesmo sentido, também do c. STJ: HC 185331-RJ, 5ª T. rel. Min. Jorge Mussi, 14.02.2012, v.U).

Levando-se em consideração as diretrizes dos artigos 42 da Lei n. 11.343/06 e 59 do Código Penal, em que pese a nocividade da droga (cocaína) apreendida, diminuo a pena no patamar máximo de 2/3 (nesse sentido: STF com repercussão geral no ARE 666.334, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 06/05/2014).

Assim, estabeleço a reprimenda definitiva, ante a ausência de outras causas de diminuição ou aumento em 01 ano e 08 meses de reclusão e o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, porquanto ausente informações acerca da situação econômica do Réu (art. 49, § 1º c/cart. 60 do CP).

Quanto ao valor da pena de multa, ausente prova que indique melhor condição econômica do acusado (CP, art. 60), é devida a fixação da pena de multa em seu patamar mínimo, ou seja, no valor de um trigésimo do salário mínimo (CP, art. 49).

V - DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, SUBSTITUIÇÃO POR PRD OU SURSIS

Por sua vez, com relação à almejada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a Resolução nº 5 do Senado, publicada em 16.02.2012, com efeito erga omnes, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", inserida no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, consagrando o princípio constitucional da individualização da pena.

Desse modo, cabe ao Julgador verificar a possibilidade de aplicação das penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 e seguintes do Código Penal.

Nessa linha, insta consignar entendimento recentemente exarado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual, em sede de julgamento do HC 118.533, por maioria de votos, decidiu pelo afastamento da hediondez do delito de tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06), por veemente desproporcional.

Tendo em vista as condições pessoais do acusado e natureza do ilícito praticado, consoante acima observado, é o caso de conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos - por igual período ao da pena privativa de liberdade, devendo ser descontado o tempo de fática reclusão -, consistentes na prestação de serviços à comunidade (a ser definida pelo Juízo das Execuções) e à limitação de fins de semana, inexistindo razão impeditiva a tal.

Por fim, em caso de descumprimento das penas alternativas, impõe-se a fixação do regime aberto para o cumprimento da reprimenda imposta (art. 33, § 1º, alínea "c" e § 2º, alínea "c"), frente ao quantum fixado e às condições pessoais do réu, aqui já consideradas.

VI - PERDIMENTO DE BENS

Não se apurando montante a ser levantado em termos de reparação de danos, deixo de fixar, sem prejuízo da via cível pertinente.

Amplamente demonstrado, que os bens apreendidos nos autos, eram utilizados para a

prática de tráfico de drogas, de rigor o decreto de perdimento dos mesmos. Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos nos autos (fls. 09/10) em favor da União, a serem revertidos ao FUNAD, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, com redação dada pela Lei nº 13.480/19.

VII – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o réu SAMUEL DOS SANTOS PEREIRA GOMES, qualificado a fls. 19, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial aberto, em virtude da prática do crime previsto no artigo 33, "caput" e § 4º, da lei nº 11.343/06, SUBSTITUÍDA por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: a-) prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo juízo da execução; e b-) limitação de finais de semana.

Em virtude do teor da presente decisão, notadamente no que tange ao regime de cumprimento de pena fixado, defiro o apelo em liberdade, na forma dos arts. 282, 311, 312 e 387, § 4º do CPP.

Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003).

Em decorrência da garantia constitucional do contraditório (art. 5º, LV da CRFB) e do princípio da congruência, deixo de fixar indenização mínima (art. 387, inc. IV do CPP).

Tratando-se de dinheiro e bens apreendido (fls. 09/10) em decorrência de Tráfico de drogas, DECRETO O PERDIMENTO dos mesmos em favor da UNIÃO (art. 91 do CP, art. 63, § 1º da Lei 11.343/2006 e Provimento 20/2006-CGJ), considerando que o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes é mandamento de criminalização insculpido no art. 243, parágrafo único, da Constituição da República; com base no qual, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 638.491/PR, julgado em 17/05/2017, foi firmada pelo Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, a tese de que o perdimento deve ocorrer "sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade (...) ou qualquer outro requisito" (tema 647).

Decreto o perdimento dos veículos e demais bens apreendidos em favor da União e deverá ser destinado ao Funad Fundo Nacional Antidrogas - nos termos da Lei Especial, art. 63, § 1º, porque é instrumento, produto ou proveito do crime em apreço. Após o trânsito em julgado, comunique-se o "Senad" quanto ao perdimento supradeterminado, instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes. Oficie-se também à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre o perdimento, instruindo-se o ofício com as cópias mencionadas no parágrafo anterior.

Proceda-se à destruição das drogas (art. 72 da Lei 11.343/06).

No caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória (Resolução 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ) para que possa postular, perante a Vara de Execuções Criminais, o que entender cabível.

Após o trânsito em julgado:

- a) lance-se o nome do Réu no rol dos culpados (art. 5º, LVII da CRFB e art. 393, inc. II do CPP);
- b) intimem-se para o cumprimento da multa (art. 50 do CPC e 686 do CPP);
- c) oficie-se ao TRE (art. 15, inc. III da CRFB);
- d) comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal;
- e) expeçam-se guias de execução e encaminhe-se à VEP.
- f) Oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a

imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente, se caso.

g) Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e a Secretária Nacional Antidrogas, para providências cabíveis, se caso.

Conforme Provimento CG nº 03/2017, que revogou o art. 1.272 das Normas da Corregedoria Judicial, as sentenças proferidas em autos eletrônicos não são mais registradas (art. 76, § 2º das Normas de Serviço).

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário. Saem os presentes intimados.

Cubatão, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA